

1500259-30.2021.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 400 porções de crack com peso bruto de 101 gramas e 86 porções de maconha, com peso bruto de 218 gramas, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

O réu foi preso em flagrante delito; sendo sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. ...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Centro - CEP 11750-000, Fone: (13) 3455-3629, Peruíbe-SP - E-mail: peruibe2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1500259-30.2021.8.26.0633 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Data da Audiência:

16/03/2022 às 15:15h

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON ROMUALDO DA SILVA

Vistos.

JEFERSON ROMUALDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c o artigo 61, II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Dois, nº 10, Jardim Somar, nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, trazia consigo, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 400 porções de crack com peso bruto de 101 gramas e 86 porções de maconha, com peso bruto de 218 gramas, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

O réu foi preso em flagrante delito; sendo sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 48/49).

O acusado foi regularmente citado e notificado (fls. 172), e apresentou defesa preliminar por meio da Defensoria Pública (fls. 120/121), recebida a denúncia (fls. 122/123).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido decretada a revelia do réu, pois, devidamente intimado, não compareceu à audiência.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição por falta de provas; subsidiariamente, a desclassificação ao delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou a fixação de penas no mínimo, atenuadas por menoridade relativa / por confissão / compensada reincidência por confissão, com máxima redução pelo privilégio, em regime brando, tomada detração, com substituição, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta parcial/integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a materialidade, pela confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado. Clara a tipicidade, não há dúvida razoável quanto à autoria. Correta a classificação dada à conduta.

Eis a prova produzida:

O policial militar ALEXANDRE FERNANDO CARNEIRO relatou em Juízo que Se recorda dos fatos. O local é conhecido como "Matinha", muito problemático por conta do tráfico de drogas. Em patrulhamento, avistaram indivíduo com a sacola nas mãos. Ao ver a presença da equipe, o réu fugiu pela mata, mas foi alcançado e abordado, ainda com a sacola. Ele não chegou a correr muito. Na sacola, havia 86 porções de maconha e 400 pedras de crack. O réu disse que havia recebido a droga de um indivíduo chamado Vitor e teria a função de abastecer o ponto de drogas. Ele chegou a indicar o local onde teria obtido a droga, na Rua Primavera, onde residiria o Vitor, que não foi localizado. Era próximo do local da abordagem, mas não sabe dizer se foi no mesmo bairro. Não conheciam o acusado anteriormente. ninguém foi abordado junto com ele, mas havia outras pessoas no local. Focaram no réu pois era ele quem estava com a sacola na mão.

O policial militar DIEGO DOS SANTOS CASTILHO descreveu em Juízo que Estavam em patrulhamento preventivo pela rua 2, em local conhecido como "Matinha", conhecido pelo tráfico de drogas. Viram indivíduo com a sacola nas mãos. Ao ver a equipe, ele tentou se evadir. Foi alcançado e abordado. Na sacola, encontraram maconha e crack. Indagado, o réu disse que abasteceria o ponto de drogas e que teria pego as drogas com um indivíduo chamado Vitor. Foram até a residência de Vitor, mas não o encontraram. Não lembra a exata quantidade, mas havia bastante droga na sacola. Ele correu poucos metros, caiu na vala e foi abordado. O local onde o Vitor morava era na Rua Primavera. Não sabe dizer o nome do bairro. Não é de Peruíbe, é de Itanhaém, por isso não conhece bem os bairros e as ruas. Não sabe precisar a distância, mas o trajeto durou cerca de 5 minutos de carro.

O réu, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 8), não compareceu em Juízo para ser interrogado, tendo dado causa à decretação da revelia, de modo que ausente alegação sua quanto à imputação. Não obstante isso, a prova colhida bem demonstra a realidade da hipótese acusatória.

É certo que o depoimento de policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

“É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 – e-book). O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485.543 – SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem os fatos quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes e harmônicos entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial acerca do ocorrido. Coerentes e precisos, expostos de forma coesa e lógica, merecem credibilidade os depoimentos das testemunhas.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que as testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu.

Bem demonstrado, assim, que o réu foi surpreendido em ponto conhecido de tráfico de drogas, na posse das substâncias.

O conjunto probatório é seguro e convincente, formado pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 12, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 15/16 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 117/119, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

A quantidade (281,2 gramas), a variedade (crack e maconha) e o modo de disposição das drogas (pequenas porções) e as circunstâncias em que apreendidas, quando postado o réu em ponto estabelecido de tráfico, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito. Nesse ponto, rejeito a tese suscitada em alegações finais pela defesa, de que a finalidade de mercancia estaria afastada pela falta de outros objetos apreendidos, como balanças ou anotações, porque as circunstâncias acima mencionadas são suficientes para determinar o fim de traficância, especialmente a quantidade de drogas, que não condiz com destinação ao consumo pessoal.

As questões suscitadas pela defesa em alegações finais atinentes à distância entre

o local em que o réu foi apreendido e o local em que supostamente teria indicado a obtenção da droga também não se afiguram aptas a afastar a materialidade ou a autoria do delito. O fato é que o réu foi surpreendido em ponto conhecido de tráfico, com as drogas sob sua posse, nada nos autos permitindo afastar essa conclusão, que decorre do acervo probatório produzido, sobretudo a prova oral.

A condenação do acusado é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, não se mostram de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, observando-se que a consideração acerca da natureza e da quantidade das drogas apreendidas importará para a determinação da fração de diminuição da pena, na terceira fase da dosimetria, razão pela qual não servirão para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido:

“(...) é preciso se atentar ao fato de que a natureza diversificada dos entorpecentes e a grande quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias que podem ser utilizadas para fundamentar a exasperação da pena-base (LD, art. 42) ou podem servir para a escolha da fração de redução de pena a ser efetivada (LD, art. 33, § 4º). Sob pena de incorrer em bis in idem, não pode o magistrado considerar essas circunstâncias na primeira e, simultaneamente, na terceira fase do processo de dosimetria da pena. A natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração (alternativamente) em uma das fases (primeira ou terceira) da dosimetria da pena, sendo vedada sua valoração cumulativa” (MASSON, Cleber, . Lei de Drogas - Aspectos Penais e Processuais. Grupo GEN, 2021 – e-book).

É esse, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“No julgamento dos Habeas Corpus 112.776 e 109.193, sob a relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Tribunal [Pleno], por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)” (STF: HC 181.841 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 29.05.2020. E ainda: RHC 182.953 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 29.05.2020).

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase.

Não atua a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, apontada na denúncia. Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo coronavírus, não se observa que essa circunstância tenha sido relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa. Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e tampouco foi impactada pela conduta da ré, não se justifica o

agravamento da punição.

Nesse sentido: Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228, deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021).

A causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º incide em grau médio frente à ausência de notícia de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Contudo, a quantidade (281,2 gramas) e a natureza das drogas comercializadas (crack e maconha) impedem a incidência da causa de diminuição em seu patamar máximo.

Aplicado o redutor em metade, vão as penas, pois, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em definitivo, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime aberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal, à vista do quantum fixado, nada autorizando a fixação de regime mais gravoso, que não pode decorrer de considerações acerca da gravidade abstrata do delito.

A propósito, é esse teor da Súmula 718 do Eg. STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada".

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: "(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal, não se afigurando a medida socialmente recomendável (art. 44, inciso III, e § 3º, CP), sobretudo tendo em vista a postura do acusado, que, colocado em liberdade sob compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, dando causa à revelia. Anoto que o zeloso escrevente de sala, em contato com o irmão do réu minutos antes do início da audiência, dele recebeu a informação de que o réu havia saído com sua genitora, mesmo sabendo da realização do ato, o que revela completo descaso com a Justiça. Por isso, é insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu JEFERSON ROMUALDO DA SILVA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, 250 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado:

- a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição;
- b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento;
- c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido ao Funad, decretado seu

perdimento em favor da União;

d) não reclamada a restituição do aparelho celular apreendido em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para sua destruição;

e) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

f) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 16 de março de 2022.

CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Juiz Substituto